

**EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Autos de origem nº: 5026724-11.2025.8.08.0024

Agravante: LUIZ ROBERTO COGO e Outros

Agravado: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, brasileira, médica, divorciada, portadora do CPF nº 111.768.167-05, residente e domiciliada à Avenida Rio Branco, 1384, Apto n. 402, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-642, **RODRIGO ALVES COGO**, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens, empresário, nascido em 28 de janeiro de 1987, portador do CPF n. 117.121.317-45, com endereço comercial à Rua João da Cruz, n. 25, Sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-620, **LUIZ ROBERTO COGO**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13 de janeiro de 1956, portador do CPF n. 809.749.108-72 e da Carteira de Identidade n. 5.086.719 SSP-SP, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630, **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22 de julho de 1959, portadora do CPF n. 032.774.148-17 e da Carteira de Identidade n. 9.498.278 SSP-SP, residente e domiciliada a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630, por seus advogados e bastante procuradores que esta subscrevem, vem, respeitosamente, perante V.Exa, interpor, a tempo e modo, o competente

AGRAVO DE INSTRUMENTO

consoante lhe faculta a Lei Adjetiva Civil, contra a respeitável decisão de ID 73073282 de lavra do eminente Juiz Titular da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual - Comarca de Vitória (ES), dos autos do processo nº 5026724-11.2025.8.08.0024 – Mandado de Segurança, em que são partes os ora Agravantes e o **SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. João Batista Parra, 600 - Enseada Do Suá, CEP: 29.050- 375 - Vitória/ES, representada judicialmente pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO localizada na Av. Nossa Sra. da Penha, 1590 - Barro Vermelho, Vitória - ES, 29057-550, pelas seguintes razões de fato e de direito que passará a expor.

Pede deferimento.

Vitoria/ES, 17 de julho de 2025.

LUCAS PIMENTA JUDICE
OAB/ES 14.477

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravante: LUIZ ROBERTO COGO e Outros

Agravado: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Autos de origem nº: 5026724-11.2025.8.08.0024

Eméritos Julgadores,

I - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso (com o **preparo** e sua **quitação** devidamente acostados) deve ser conhecido por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade. O pressuposto quanto ao “**Cabimento**” (art. 1015, I, CPC) será abordado no próximo tópico (Exposição dos Fatos) com o recorte da decisão ora recorrida.

No que pertine à **tempestividade**, ressalta-se que o Agravante tomou ciência da decisão interlocutória, ora atacada, mediante **publicação no Diário Oficial dia 16 de julho de 2025**, de modo que o prazo para a interposição do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO começou a fluir em 17/07/2025 (uma quinta-feira). Considerando-se o previsto no artigo 219 do NCPC (*contagem de prazo somente em dias úteis*) o prazo final para a apresentação desta peça seria 06/08/2025 (uma quarta-feira). Sendo assim, o presente Agravo protocolado dia 17 Julho/2025 é tempestivo.

- O que se busca com esse Agravo de Instrumento

Os impetrantes buscam a reanálise do pedido liminar de **para determinar à autoridade coatora que se abstenha de emitir guias e/ou cobrar ITCMD em relação às Declarações n. 20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989 (suspensão de exigibilidade)**, diante do *fumus bonis iuris*, *periculum in mora* e a ausência de prejuízo ao Estado.

Subsidiariamente, objetiva-se o deferimento de depósito judicial no valor de R\$ 121.207,60 (*cento e vinte e um mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos*) - ou 4% sobre valor cedido conforme patrimônio líquido das empresas, como forma de garantir a suspensão da exigibilidade tributária.

II – EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DAS RAZÕES DO RECURSO

Os impetrantes são sócios de duas sociedades empresárias nas quais, em Julho de 2025, houve doações de cotas sociais entre os recorrentes. A transmissão não onerosa foi informada à Secretaria da Fazenda Estadual através das Declarações n. 20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989 em 11 de Julho de 2025, data a partir da qual as partes poderiam/podem ter contra si exaradas cobrança de ITCMD - **ilegais no caso presente.**

Como cediço, o Estado do Espírito Santo sempre cobrou - corretamente - o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação quando do fato gerador morte ou cessão não onerosa. No ES, a Lei 10.011/2013 é o último diploma legal que regulamenta a cobrança.

No entanto, em 21 de Dezembro de 2023 os Constituintes Derivados promulgaram a Emenda Constitucional n. 132, data a partir da qual os artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual 10.011/2013 foram extirpados e, assim, vedada está qualquer cobrança de ITCMD, por força do art. 150, CF.

Essa nova EC modificou o art. 155 da CF (*que concede aos Estados a competência do ITCMD*). Antes da EC 132, os estados tinham a **opção/faculdade** de escolher pela alíquota fixa ou pela alíquota progressiva. A partir da EC, no entanto, a Constituição passou a **obrigar a alíquota fixa**. Passados mais de 18 meses da nova ordem constitucional, a legislação local continua incompatível com o novo preceito Magno, para além de ter sido extirpada face à imediata revogação tácita e por assimilação (detalhado à extensão abaixo).

A revogação tácita de leis infraconstitucionais frente superveniente EC é o cerne desse recurso, e não se pode falar que é um tema ausente de plausibilidade. A decisão atacada, no entanto, entende que não há plausibilidade no direito, de modo a sequer permitir melhor apreciação da tutela de urgência subsidiária (*depósito judicial*).

Breve síntese dos fatos e da decisão recorrida: Em razão do risco de exação tributária indevida (*vide EC 132*), as partes impetraram o **Mandado de Segurança Preventivo** registrado sob o n. 5026724-11.2025.8.08.0024, com o objetivo de ter analisada e deferida liminarmente a suspensão da exigibilidade tributária até julgamento de mérito. De maneira subsidiária, ainda fora requerido depósito judicial de valor compatível com 4% do montante doado, de forma a servir

como outra maneira de suspender a exação fiscal do ITCMD *no valor de R\$ 121.207,60 cento e vinte e um mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos*.

Não obstante os **milhares** de julgados do STF, STJ e do próprio TJES no que toca ao instituto da revogação em matéria tributária, o MM. Juiz de piso entendeu que no *mandamus* em tela não seria plausível arguir que uma alteração constitucional teria o poder de revogar tacitamente (*ou por assimilação*) uma lei infraconstitucional:

Trecho da Decisão Recorrida: “No presente caso, os impetrantes sustentam que a Lei Estadual no 10.011/2013, ao prever alíquota fixa de 4% para o ITCMD, teria se tornado materialmente incompatível com o novo art. 155, § 1o, inciso VI, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 132/2023, que passou a exigir, expressamente, a progressividade da alíquota do imposto.

Entretanto, não assiste razão à pretensão deduzida neste momento processual. Embora seja fato que a EC no 132/2023 incluiu norma que estabelece a obrigatoriedade da progressividade do ITCMD, **tal dispositivo não tem aplicabilidade imediata, tampouco opera revogação automática das normas estaduais preexistentes.**”

Com a devida vênia ao H. Julgador de Origem, a sua conclusão de que a EC 132/23 não revoga de imediato à legislação estadual está contrária à 3.441 decisões das Cortes Superiores desde 2000 sobre o mesmo tema¹, que, à unanimidade, reconhecem a extirpação imediata de leis revogadas tacitamente por EC, sendo que um pequeno grupo de decisões (14%) indicam a necessidade de se demonstrar a “incompatibilidade material” (*que também é presente no caso do ITCMD do ES*):

Das 3.441 decisões analisadas:

- **86% são favoráveis à revogação tácita imediata e incondicionada** de leis infraconstitucionais com o advento de Emenda Constitucional
- 14% entendem que precisa ser provada a “**incompatibilidade material**” para, assim, reconhecer a revogação da lei infra

No caso concreto, a decisão nada aborda sobre “incompatibilidade material”, seguindo o magistrado um **raciocínio completamente oposto ao dos Tribunais Superiores** ao preceituar que apenas uma revogação expressa cessaria os efeitos da lei até então vigente:

¹ Via Turivius IA. Abaixo colacionamos o estudo detalhado de uma estratificação de 120 julgados dentre esses 3.441 pesquisados, decisões essas representativas da opinião histórica do STF e STJ quanto ao tema.

“Não há qualquer comando constitucional que determine a revogação imediata da legislação estadual atualmente em vigor. [...] Assim, **diante da ausência de norma estadual posterior que tenha revogado expressamente a legislação vigente**, da inexistência de ato coator efetivo, e da inaplicabilidade imediata da EC no 132/2023 sem a edição de lei estadual regulamentadora, não se vislumbra, em sede liminar, a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar.”

O d. Juiz ainda encampa visão financeira (e não jurídica) das decisões judiciais, o que não deve se aplicar ao ITCMD, haja visto decisão do STF, de Março de 2025, na qual entenderam os Ministros, à unanimidade, que **o ITCMD não tem cunho social para gerar tamanha preocupação consequencialista**, para além de corresponder o ITCMD a apenas 0,48% (*média*) da arrecadação dos Estados.

Trecho Consequencialista da Decisão Atacada “Se assim fosse, os Estados que ainda não aprovaram leis para estabelecer o ITCMD progressivo, quais sejam, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Bahia e Piauí [...] **teriam grave crise arrecadatória**, o que, convenhamos, não foi o objetivo do Constituinte Derivado.”

Por fim, em termos de razões de validade levadas à cabo na decisão recorrida, o Magistrado esboça dois argumentos balizadores de sua decisão (progressividade do IPTU no *Tema 226 e progressividade não imposta por 28 anos do Imposto de Renda*). Com o devido acato e respeito, entende-se não terem sido devidamente ajustados à realidade em discussão, o que será também destacado em capítulo próprio.

Cumprir destacar, ainda, que o STF, no julgamento do **Tema 226 da Repercussão Geral (RE no 602.347/MG)**, enfrentou **questão análoga ao analisar a progressividade do IPTU e decidiu que, mesmo reconhecida a inconstitucionalidade da progressividade indevida, o tributo poderia continuar sendo exigido com a alíquota mínima prevista na legislação**. Embora o caso trate de IPTU, o raciocínio é perfeitamente aplicável ao ITCMD, pois não há alíquota progressiva já definida no ordenamento jurídico capixaba.

Exemplificativamente, desde 1988, a Constituição **prevê a progressividade do Imposto de Renda (IR), mas esta só foi instituída para a tributação do ganho de capital pela Lei no 13.259, de 2016, e nem por isso a cobrança da alíquota fixa nesses casos foi considerada inconstitucional durante o período de 28 anos entre as normas**.

O *decisum* recorrido ainda desconsidera o inequívoco direito do contribuinte em depositar judicialmente o *quantum debeat* para conseguir a suspensão da exigibilidade (CTN, 151, II). Argumentou o magistrado que o *writ* não possui plausibilidade mínima a autorizar o cumprimento

de um direito unilateral dos Impetrantes. Importa ressaltar que o MS foi protocolado dia 14 de julho e a decisão proferida no dia 15 de julho, sem ter dado tempo suficiente para as partes procederem ao depósito judicial antes de terem a negativa pelo Juiz:

Trecho da Decisão Recorrida: À míngua da evidência do direito autoral, **também deixo de deferir o pedido para depósito nestes autos, a fim de suspender a exigibilidade desse tributo**, pois mesmo a hipótese do art. 151, II, CTN, exige a mínima plausibilidade do direito invocado na exordial, a qual não verifiquei, ao menos em sede de cognição sumária.

Desta forma, e sem prejuízo de outros elementos jurídicos já abordados na exordial, este Agravo de Instrumento terá o foco principal de rebater as razões decisórias de piso, notadamente:

1. Plausibilidade do Direito, Reforço da Tese Autoral e Combate aos Argumentos da Decisão Liminar
 - a. Inobservância à farta jurisprudência das Cortes Superiores quanto à revogação imediata de norma infraconstitucional frente posterior EC; → razões a justificar a medida liminar
 - b. Inadequação do uso do Tema 226 (progressividade do IPTU) para o caso concreto; → fundamentação inadequada da decisão recorrida
 - c. Inadequação do comparativo com a progressividade do Imposto de Renda, só implementado 28 anos depois da CF. → fundamentação inadequada da decisão recorrida
 - d. Ativismo Judicial: decisão de março de 2025 reconhecendo que o ITCMD **não** é tributo que - uma vez não cobrado - gera grave crise arrecadatória; → fundamentação inadequada da decisão recorrida
2. Da necessidade de reanálise da medida liminar
 - a. Fumus Bonis Iuris, Periculum In mora e Reversibilidade da Medida
 - b. Subsidiariamente: inequívoco direito de depósito judicial, negado pela decisão recorrida

III – RAZÕES DO PEDIDO E DA REFORMA DA DECISÃO: Plausibilidade do Direito e Requisitos Para Concessão da Suspensão da Exigibilidade Tributária

Como discorrido acima, esse Agravo de Instrumento rebaterá os principais pontos da decisão recorrida, para além de reforçar argumentos adicionais atinentes à *quaestio iuris*.

1. Inobservância à farta jurisprudência das Cortes Superiores quanto à revogação imediata de norma infraconstitucional frente posterior EC;
2. Inadequação do uso do Tema 226 (progressividade do IPTU) para o caso concreto;
3. Inadequação do comparativo com a progressividade do Imposto de Renda, só implementado 28 anos depois da CF.
4. Ativismo Judicial: decisão de março de 2025 reconhecendo que o ITCMD **não** é tributo que - uma vez não cobrado - gera grave crise arrecadatória;
5. Concessão da Tutela de Urgência: *fumus bonis iuris*, *periculum in mora* e ausência de prejuízo na concessão

Ab initio, cabe restaurar a percepção da plausibilidade do direito, equivocadamente não observada pelo Magistrado de piso. O ponto nevrálgico do *writ* é a revogação tácita ou por assimilação das normas infraconstitucionais frente à superveniente Emenda Constitucional.

Esse não é um tópico novo, e este causídico ora subscritor fez uma análise de mais de 3.441 julgados sobre o tema nas cortes superiores, cuja estratificação de jurimetria segue ao final do tópico (1) abaixo com o resumo das 120 decisões mais recentes das Cortes Superiores sobre o tema. O reconhecimento da revogação tácita frente EC posterior é **unânime** entre os Ministros do STF e STJ, e apenas 14% daqueles condicionam o reconhecimento de tal revogação à um debate e comprovação quanto à incompatibilidade material da lei infra com a nova ordem constitucional - incompatibilidade essa não investigada pela decisão de piso mas presente no caso em apreço.

O argumento jurídico desse Mandado de Segurança é de fato inovador no que pertine a aplicar o já batido entendimento de revogação tácita vide EC agora quanto à irregular e ilegal cobrança de ITCMD no Estado do Espírito Santo (a partir da EC 132/2023). Apesar de tema novo, está repleto de plausibilidade e reforço jurisprudencial.

1. Inobservância à farta jurisprudência das Cortes Superiores quanto à revogação imediata de norma infraconstitucional frente posterior EC; Inexistência de Legislação Estadual que autorize a cobrança de ITCMD a partir de 21/12/2023

Buscando-se recuperar a “plausibilidade” do direito em tela, e tendo em mente que o tema precípua desse *mandamus* é a revogação tácita ou não de legislação infraconstitucional frente à posterior Emenda Constitucional, colaciona-se diversos julgados que reforçam o entendimento **unânime** do STF e STJ pela possibilidade de revogação tácita.

Inicia-se com o principal precedente de 1992 que até hoje é utilizado como voto condutor para explicar a diferença entre “inconstitucionalidade superveniente” de “revogação por não-recepção” de lei, concluindo o julgado que “**Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária.**”

STF - ADI: 2 DF, Relator.: Min . PAULO BROSSARD, Data de Julgamento: **06/02/1992**, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 21-11-1997 PP-60585 EMENT VOL-01892-01 PP-00001 CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. **Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente**; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. **A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária.**

Outras várias decisões reforçam a relevância do tema e a plausibilidade do argumento:

(STF - ADI: 7743 MT, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: **28/11/2024**, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28/11/2024 PUBLIC 29/11/2024) Conforme jurisprudência desta Corte, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto quando sobrevém **a revogação da norma questionada**, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado. Veja-se: ADI nº 6.416-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21); ADI nº 5.987/AM AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21); ADI nº 5.145/MA AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20); ADI nº 2.049/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19); ADI nº 4.389-AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18); e ADI nº 1.378 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11). É certo, ademais, **que a jurisprudência também admite a prejudicialidade por revogação tácita** do objeto impugnado (v.g. ADI nº 4583/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/20; ADI nº 2352/ES, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/11; ADI nº 1.056/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 3/10/97; ADI nº 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 24/6/1994; ADI nº 2.006/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno,

DJ de 10/10/08; ADI nº 3.831/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/07; ADI nº 1.920/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 2/2/07; ADI nº 1.952/DF-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 9/8/02; ADI nº 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 6/6/97). In casu, portanto, forçoso concluir que a presente ação direta de inconstitucionalidade não comporta conhecimento, **porquanto seu objeto foi tacitamente revogado por legislação superveniente, não impugnada pelo requerente.**

(STF - ADI: 4984 CE, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 12/04/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/04/2018) CONSTITUCIONAL. LEIS COMPLEMENTARES 1/1994 E 84/2009 DO ESTADO DO CEARÁ. NORMAS GERAIS. ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL . EC 15/1996. NOVA CONFORMAÇÃO DA MATÉRIA. LEI ESTADUAL REVOGADA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FIXAR PERÍODO DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MUNICÍPIOS . ESTABELECIMENTO DE DEVERES E OBRIGAÇÕES PARA A JUSTIÇA ELEITORAL POR MEIO DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, NESSE PONTO. 1 . **A promulgação de Emenda Constitucional enseja revogação dos atos normativos anteriores que lhe são contrários.** 2. Competência da União para fixar lapso temporal em que permitida a criação, a incorporação, a fusão ou o desmembramento de municípios (CF, art. 18, § 4º, com redação dada pela EC 15/1996) . 3. A União é competente para estabelecer normas gerais acerca do processo de criação de municípios, o que não obsta a competência suplementar dos Estados-Membros. 4. Impossibilidade de criação, fusão, incorporação ou desmembramento de municípios antes do advento de Lei Complementar federal definindo o período em que autorizado . 5. Os Estados-Membros são incompetentes para designar obrigações para a Justiça Eleitoral, que integra a Justiça Federal. 6. Ação julgada parcialmente procedente .

(STF - ARE: 825237 RJ, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 31-10-2014 PUBLIC 03-11-2014) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO . **REVOGAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE.** PRECEDENTES . Não há direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária. Ademais, nos termos da jurisprudência da Corte, a disposição revogada não consagra direito ou garantia fundamental. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TJ-MG 100000027501980001 MG 1 .0000.00.275019-8/000(1), Relator.: MARIA ELZA, Data de Julgamento: 05/09/2002, Data de Publicação: 15/10/2002) Contribuição previdenciária - Inativos - Lei n 12.278/96 - Admissibilidade - Inconstitucionalidade não declarada - Sentença que se reforma. V.V .P. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS. NÃO RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20. De acordo com entendimento firme do Supremo Tribunal Federal, o art . 2º, IV, e **a expressão ""proventos de aposentadoria"" do art. 3º, ambos da Lei Estadual 12.278/96, não foram recepcionados pela nova ordem constitucional previdenciária estabelecida pela Emenda Constitucional 20/98**, que proíbe a instituição e cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos.

Para não deixar essa peça ainda mais longa, lista-se outros precedentes reconhecendo a revogação tácita no STF, sem, por ora, transcrever a ementa:

ADI nº 4583/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/20
ADI nº 2352/ES, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/11
ADI nº 1.056/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 3/10/97

ADI nº 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 24/6/1994

ADI nº 2.006/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 10/10/08

ADI nº 3.831/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/07

ADI nº 1.920/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 2/2/07

ADI nº 1.952/DF-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 9/8/02

ADI nº 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 6/6/97

Não apenas o STF reconhece a extirpação de lei por revogação tácita. Em se tratando de matéria tributária, o CARF tem grande relevância jurisprudencial e também acolhe a revogação tácita, a despeito de, por vezes, ter um olhar pró-Fisco. Recorremos ao excelente artigo do Professor Diego Diniz Ribeiro (*Direto do CARF: Revogação tácita e revogação expressa à luz da jurisprudência do Carf*²), que assim compartilha:

Nesse sentido, a primeira decisão a ser analisada está veiculada no **acórdão Carf nº 3101-000.256**. Nesse caso, o contribuinte alegava a nulidade do lançamento perpetrado ao fundamento de erro na sua motivação. Segundo o contribuinte, o lançamento da multa de 50% pelo não retorno ao exterior de mercadoria submetida ao regime de admissão temporária deveria ter sido capitulado no artigo 106, inciso II, "b", do Decreto-Lei nº 37/66, e não no disposto no artigo 72, inciso I, da Lei 10.833/03, uma vez que esse último prescritivo legal não teria expressamente revogado o primeiro, o que conflitaria com o artigo 9º da citada Lei Complementar 95/98. **Ao analisar a questão, o relator do caso, acompanhado por unanimidade, aduziu que o artigo 9º da LC nº 95/98, aboliu a chamada revogação genérica, traduzida pela expressão "revogam-se as disposições em contrário", mas que, todavia, não desapareceu do sistema jurídico a revogação tácita, porquanto é impossível ao legislador ter presente, o tempo todo, a perfeita compreensão dos efeitos que as normas jurídicas contidas no texto legal terão sobre as demais normas já constantes do sistema jurídico.**

Parece haver uma confusão aqui: o entendimento do Carf e do STJ é, de fato, no sentido de não ter ocorrido a revogação tácita do artigo 77, II, da Lei nº 8.981/95, pelo artigo 5º da Lei nº 9.779/99, e não no sentido de rejeitar a revogação tácita enquanto instituto, o que são coisas distintas. **A jurisprudência do Carf, como demonstrado acima, nunca adotou essa linha [de rejeitar a revogação tácita], ao passo que a Primeira Seção do STJ, no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.050.430 [14], pacificou a inocorrência de revogação tácita nesse caso, mas pontou em seu voto que "Há revogação tácita quando, de forma implícita, há incompatibilidade entre o texto anterior e o posterior. Segundo a melhor doutrina, essa incompatibilidade deve ser absoluta. Não pode partir de meras presunções"**, rejeitando expressamente a exigência de revogação expressa.

No acórdão **Carf nº 1301-002.974**, reconheceu-se a possibilidade expressa de revogação tácita, com base no artigo 2º, §1º, da LINDB, mas rejeitou-se sua ocorrência no caso concreto, em relação a uma pleiteada revogação do artigo 42 da Lei nº 9.430/96 pelo artigo 5º, §4º, da LC nº 105/2001.

Como mencionado acima, este patrono signatário conduziu estudo (com apoio de inteligência artificial - [Turivius.com](https://www.turivius.com)) para identificar a visão majoritária das Cortes Superiores sobre o referido tema. A conclusão foi no sentido de que 86% dos julgamentos sobre a questão de revogação

² <https://www.conjur.com.br/2020-jul-01/direto-carf-revogacoes-tacita-expressa-luz-jurisprudencia-carf/>

tácita no STF e STJ reconhecem - sem condicionantes - que as leis infraconstitucionais não recepcionadas são de imediato revogadas.

Em 14% dos julgados, no entanto, alguns ministros reconhecem a revogação tácita, mas condicionam o reconhecimento à discussão e identificação prévia da **incompatibilidade material** entre a norma pré e a nova Ordem Constitucional. Vejamos um exemplo dessa exegese:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.247.098 - MS (2011/0074787-0)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

“O que foi feito, repise-se, foi a supressão de qualquer requisito referente à separação prévia para requerer o divórcio, e não a supressão do instituto em si. **Não há conflito, portanto, entre o disposto na Constituição Federal e o prescrito na legislação infraconstitucional.**”

Depreende-se da leitura que, naquele caso, a Ministra Maria Isabel Gallotti entendeu por bem justificar que não havia incompatibilidade ou conflito material entre a EC e a lei anterior. No presente caso, o Magistrado de Piso **nada comentou sobre incompatibilidade ou não** da lei. Independente, a incompatibilidade é evidente e gritante, pois em nenhum momento se deu a faculdade da progressividade (como foi no IR ou no IPTU), mas a obrigatoriedade (vide capítulo próprio).

O que foi levantado na decisão recorrida foi o entendimento de que haveria a “necessidade de regulamentação” via lei estadual específica do art. 155, pár. 1o, inciso I, **o que está cabalmente errado.**

Trecho da Decisão Agravada: O texto constitucional exige, para sua concretização, a edição de lei específica estadual que discipline os critérios de progressividade, respeitado o princípio da legalidade estrita em matéria tributária (art. 150, I, da CF/88)³.

A Emenda Constitucional 132 de 2023 **não exigiu**, para sua concretização, **a edição de lei específica estadual**. E a visão sistêmica tampouco corrobora com o racional de que os Estados tem a liberalidade de aderir, ou não e quando quiserem, o mandamento Superior. Essa leitura é uma desvirtuação do entendimento de competências constitucionais e uma falha de interpretação do que significam e para que servem as **normas gerais** e do próprio princípio da legalidade.

³ A referência ao art. 150, I, CF não faz sentido nesse contexto.

- **CF como Normal Geral não dependente de Lei Complementar Estadual para seu requisito de efetivação**

Vamos a um exemplo do TJES. No julgado de relatoria do Desembargador Namyr Filho, n. 0000812-77.2022.8.08.0000, discutia-se sobre a modificação constitucional das regras de aposentadoria para membros do Ministério Público face EC n. 88. Neste caso, a Emenda Constitucional era **expressa** ao requerer Lei Complementar posterior para regular a matéria lá posta:

Trecho da Decisão Processo 0000812-77.2022.8.08.0000: “Com efeito, a despeito de a regra estipular a possibilidade de a aposentadoria compulsória operar-se aos 75 (setenta e cinco) anos, certo é que assim será tão somente nas hipóteses disciplinadas **“na forma da lei complementar”**. Desta feita, **por depender de regulamentação e integração por norma infraconstitucional, no caso, a indispensável edição de Lei Complementar, infere-se que tal preceito constitucional traduz-se em típica norma de eficácia limitada**. É dizer, em outras palavras, que a sua aplicação não se faz possível com a mera vigência da Emenda Constitucional que o instituiu, no que a existência de Lei Complementar, disciplinando as hipóteses de aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, afigura-se imprescindível para aplicá-la.”

Esse **não é o racional da Emenda Constitucional n. 132/2023**. A mudança trazida no art. 155, CF, com a adição do novo inciso VI (*“será progressivo [o ITCMD] baseado no quinhão, legado ou doação”*) não requer Lei Complementar para definir **a norma geral**.

O foco desse Agravo é, como dito, recuperar a noção de plausibilidade para que o pedido liminar seja deferido. Não se objetiva, portanto, tratar toda a matéria de direito que ainda será discutida em jurisdição de piso. Assim sendo, pede-se vênha para reportar esse E. Relator - caso entenda pertinente - à petição inicial do MS de Piso, notadamente no tópico ***“Posição Atual do STF sobre a não recepção de leis incompatíveis após EC”***, onde dedicamos diversas páginas sobre o tema da norma geral e a “totalidade do tema” abordado pelo artigo 155, § 1o, VI, CF.

Em resumo, e nas palavras do Professor Pós-Doutor Adrian Sgarbi **“um só artigo pode revogar - por assimilação ou tacitamente - todo um código”**.

Por outro lado, e se o foco é recuperar a “plausibilidade” do tema, é imperativo mencionar que a matéria constitucional da EC 132 é de norma geral (**progressividade ou não**), de modo que o

detalhamento Estatal (se 1, 2, X ou 8%) não é requisito de validade para impor a progressividade, posto que a norma geral - reitera-se, já está promulgada via EC 132/23.

Compare-se o texto da EC 132 ("será progressivo" e "ponto") com a EC 88 art 40, conforme julgado do H. Desembargador Doutor Namyr Filho acima, onde o próprio constituinte derivado prescreveu que - naquele caso, seria necessária uma lei complementar para a efetividade do novo texto Magno.

No mesmo sentido, o DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, DESEMBARGADOR MARIANNE JUDICE DE MATTOS, SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR, DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

A EC 132/23 valeu-se de várias formas de eliminação de normas, seja pela da revogação expressa (*como no art. 22 daquela*) como também pela revogação tácita e por assimilação, haja visto que o art. 155, § 1o, VI trata, em si, a totalidade do tema do ITCMD no que toca à norma geral (art. 146, CF) competente à CF (ainda que o específico - não norma geral - caiba aos estados).

Voltemos um pouco para entender melhor este ponto. A Carta Magna estabelece a regra geral tributária, definindo as competências, hipóteses tributárias e limites no que toca ao fato gerador e base de cálculo. A leitura sistêmica assim dispõe:

CTN

Art. 18. **Compete:**

I - **à União, instituir**, nos Territórios Federais, **os impostos atribuídos aos Estados** e, se aqueles não forem divididos em Municípios, cumulativamente, os atribuídos a êstes;

CF

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar **concorrentemente** sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer **normas gerais**.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre **normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.**

Art. 146, III: Cabe à lei complementar

a) **definição de tributos e de suas espécies**, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos **atos geradores, bases de cálculo e contribuintes**,⁴ → definição de "normas gerais"

É dizer, a norma geral da regra matriz é função Constitucional, e a foi feita à totalidade quando a EC trouxe o texto "será progressivo". Esse superveniente texto, portanto e à luz do § 4º do art. 24, é começo, meio e fim de uma norma geral, dentro dos limites constitucionais, que, assim, suspende eficácia de lei estadual.

E não se argumente que o art. 146, III da CF obriga que uma lei complementar (*federal ou estadual*) defina a norma geral, como se o inciso constitucional por si só não o pudesse fazê-lo em termos de normativo abstrato/geral. Renomados autores como Paulo de Barros Carvalho e Roque Carrazza⁵, entendem que a Lei Complementar referida pelo art. 146, III, CF está constricta a apenas dispor sobre conflitos de competência entre os Entes Federados ou à **regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar**, sendo o inciso III, alínea "a" um dispositivo que apenas valida a edição de LC respeite a **norma geral já estabelecida pela CF** em artigos de caráter tributários.

A revogação tácita ou por assimilação exige "incompatibilidade material", o que já fora deveras demonstrado quando dos tópicos da vontade clara e expressa do legislador constituinte em escolher o predicado verbo-nominal "será progressivo" ao revés de "poderá".

- Incompatibilidade Material → Existência

Um tema recorrentemente discutido nos STF e STJ é a caracterização do termo "incompatibilidade material". O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a perda superveniente de objeto nos controles abstratos de constitucionalidade diante de alteração normativa, adota o critério da "alteração substancial" ou "incompatibilidade material" para distinguir entre hipóteses em que a ação perde o objeto e aquelas em que subsiste a necessidade de análise do mérito por possível "fraude processual" (isto é, para impedir burla à jurisdição constitucional), **conforme julgados listados no documento anexo "Fontes do STF" sob ns. 59, 84 e 82.**

⁴ O novel artigo 155, I, parágrafo 1º, inciso IV ("alíquota progressiva") define norma geral, e contém em si os elementos para composição da base de cálculo e o regramento matriz de incidência e aplicação tributária, seja no quesito de progressividade ou não da alíquota como quanto ao cálculo baseado no quinhão ou cota-parte transmitido ou doado.

⁵ CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 15. Ed., p. 210-211; CARRAZZA, Roque, Curso de Direito Constitucional Tributário, 12. Ed., p. 510

Não basta a mera redução do âmbito de incidência — é essencial analisar se o conteúdo normativo foi substancialmente alterado ou tornado incompatível, materialmente, com o novo regime jurídico - **Doc 5 Anexo Fontes STF - (82) (84) (59) e (121)**.

Nos julgamentos da ADI 1080 e da ADI 2049, o STF assentou que a **alteração substancial do conteúdo normativo implica revogação tácita**, sendo tal análise eminentemente material, ou seja, centrada na efetiva incompatibilidade de conteúdos — não em mera revogação formal ou repetição da norma (59) (84). Quando há apenas redução do campo de aplicação ou nova redação sem modificação substancial, a ação pode subsistir (82) (59). No que pertine ao ITCMD, não houve uma “redução no campo de aplicação”, mas uma completa alteração da ordem mandatória, saindo do predicado “poderá ser progressivo” para o “é impreterivelmente progressivo o ITCMD”. A mudança não é singela.

No controle concentrado, a “incompatibilidade material” também foi utilizada nos debates sobre emendas constitucionais, quando a norma nova regula **“integralmente a matéria”** da anterior de forma contraditória ou substitui o regime anterior por novo sistema jurídico, restando incompatível com a ordem normativa superveniente (cf. art. 2º, § 1º, LINDB). → Essa leitura corrobora em cheio com esse mandado de segurança.

A leitura dos acórdãos demonstra que a caracterização de incompatibilidade é eminentemente substancial e não meramente formal, e deve ser motivada segundo critérios objetivos extraídos do novo regime jurídico e da finalidade da norma anterior (84) (121) (62). Trata-se de categoria intertemporal central para a adequada articulação dos sistemas normativos diante da superveniência de nova disciplina constitucional/material. - **Doc 5 Anexo Fontes STF - (59) (82)**.

Além disso, nos julgamentos relativos à revogação de benefícios previdenciários, gratificações ou regimes jurídicos extintos por ECs ou reformas legislativas (por exemplo, ADI 3777/BA, ADI 4154/GO, ADI 761/BA, RE 594.481/DF), o STF tem aplicado o entendimento de que “incompatibilidade material” exige a total substituição da disciplina anterior ou flagrante contradição dos fundamentos, vedando repristinação automática salvo disposição expressa. O conceito é frequentemente fundado, inclusive, no art. 2º, § 1º, LINDB — a lei (ou EC) posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, “quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior” (98) (121) (79) (30) (106).

E aqui voltemos ao tópico anterior: o artigo 155, § 1o e seu novel inciso VI **é a totalidade da matéria no que pertine à visão de norma geral**. Dito de outra forma, não é necessária lei complementar que explique ou defina o que significa ou em quais casos serão aplicadas a progressividade. Ela é, como manda a Constituição, obrigatória, de modo que as leis estatais servem apenas para se conformar à essa ordem com as minúcias locais do *quantum* entre as faixas de gradação, mas não a definição se fixa ou progressiva.

O conceito é relevante tanto na análise da revogação tácita quanto para o juízo de prejudicialidade na ação de controle concentrado. Sua aplicação concretiza-se na verificação da alteração substancial e na compatibilidade de conteúdos entre normas sucessivas (84)(121)(59)(82) e (61).

- Estudo de Direcionamento do STF quanto à revogação tácita por EC superveniente

Por derradeiro, quanto à esse tópico, e para reforçar o argumento da plausibilidade do tema, procedemos a um completo estudo de posicionamento do STF sobre o tema da revogação tácita frente nova EC. Nos anexos desse Agravo, trazemos uma documento de nome “Fonte” que traz os links de cada decisão mencionada no quadro abaixo:

Processo / Ementa	Relator(a)	Entendimento sobre revogação tácita (condicionada ou não)	Objeto discutido (questão central)	Fonte (ver anexo para Inteiro Teor de Cada Fonte)
ADI 1.080 (QO-ED), ADI 2049, ADI 4583, ADI 3.517, ADI 3.502	Ministros Rosa Weber / outros	REGRAL: Revogação (expressa ou tácita) de lei infraconstitucional por alteração substancial ou superveniência de nova lei/Emenda constitucional acarreta, em regra, perda do objeto da ação direta , independentemente de efeitos concretos residuais, salvo fraude processual (revogar para burlar controle judicial) ou repetição de teor da norma anterior em novo diploma [59][84][61][121][97].	Perda de objeto de ação direta de inconstitucionalidade por revogação superveniente ou alteração substancial normativa.	[59], [84], [61], [121], [97]
ADI 4.182, ADI 3517, ARE 1334772	Ministros Rosa Weber, Nunes Marques, Gilmar Mendes	Revogação tácita, inclusive por alteração substancial (não só expressa). A revogação (ou alteração substancial do conteúdo) acarreta extinção superveniente do objeto da ação . A repetição do conteúdo (norma idêntica) pode ensejar aditamento da inicial, salvo fraude [84][121][102].	Perda de objeto por revogação tácita/alteração substancial – controle concentrado.	[84], [121], [102]
ADI 3777, ADI 761, ADI 570, ADPF 97, RMS 27.966/SP	Min. Luiz Fux, Min. Roberto Barroso, Min. Rosa Weber	As normas estaduais/locais sobre vinculação ou equiparação remuneratória foram revogadas (não-recepcionadas) por emenda constitucional (CF/88 ou EC 19/98) . Não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração; vedação à vinculação equiparação é autoaplicável (revogação tácita) [85][107][106].	Vedação a equiparação/vinculação remuneratória. Não-recepção automática após EC/CF.	[85], [107], [106], [62]

AgInt no RMS 69039/GO, RE 1363132/SC	Min. Gurgel de Faria, Min. Dias Toffoli	O esvaziamento da norma constitucional por EC pode tornar sua eficácia limitada ou dependente de lei futura, não equivalente a revogação (carece de lei ordinária para efeito concreto) [75][119]. → Essa hipótese se assemelha ao caso acima relatador pelo Desembargador Namy Filho, que não se aplica ao presente processo pois a EC132 não limitou a norma geral à uma LC posterior.	Abono de permanência de servidor – necessidade de lei local após EC 103/2019.	[75], [119]
ADI 761/BA, ADI 3777/BA, ADI 3295/ES, ADI 3644/SC, ADI 4154/GO	Min. Cezar Peluso, Min. Luiz Fux, outros	A simples redação nova de EC vedando equiparação automática implica imediata revogação tácita das normas locais/materialmente incompatíveis [85].	Vedação constitucional à equiparação, revogação tácita.	[85]
REsp 1.247.098/MS, REsp 1.788.114 / PR, REsp 1.753.135 / RS, AGINT no REsp 619.436 / RS	Min. Maria Isabel Gallotti, Min. Nancy Andrighi, outros	Revogação tácita de norma infraconstitucional por EC ou lei federal ocorre quando a matéria é inteiramente regulada ou há incompatibilidade (art. 2º, §1º, LINDB). Edição de EC pode revogar/invalidar incompatíveis, sem necessidade de previsão expressa [78][98][118][79].	Extinção do instituto da separação, extinção de dívida por falecimento em consignado, regras de aposentadoria, etc.	[78], [98], [118], [79]
RE 594.481 / DF ("Férias 60 dias PFN"), ED-SEGUNDO S	Min. Luís Roberto Barroso	Tratamento de revogação expressa (art. 18 da Lei 9.527/1997) e revogação tácita (equiparação vencimental) por lei/EC posterior incompatível .	Cessaç�o do direito a férias de 60 dias – extinção por revogação expressa/t�cita da base legal	[92], [89], [30], [68]
ADI 5946 ED-TERCEIRO S / RR (Emenda estadual)	Min. Gilmar Mendes	Correção de erro material; rejeição da preliminar de perda de objeto por revogação (por alteração formal, mas não substancial) – quando a revogação não altera o conteúdo normativo atacado, mantém-se o objeto [65][57][90][101].	Revogação de emenda estadual – discussão de vício formal X alteração substancial	[65], [57], [90], [101]
ADI 1080, ADI 2049	Min. Rosa Weber, outros	A alteração substancial de texto normativo (e não mera redução do �mbito de aplicação) enseja perda de objeto – revogação ou alteração que altera a subst�ncia enseja extinção da a�o [59][84].	Distinção perda de objeto por alteração substancial ou mera redução de �mbito	[59], [84]

Vide Doc 6 Anexo "Fontes STF" - item (3) para o inteiro teor de cada decis o citada

No doc 5 (anexo: Fontes) junta-se outra jurimetria do **TJES** sobre o mesmo tema, com 20 decis es recentes detalhadas por Relator.

2. Inadequa  o do uso do Tema 226 (progressividade do IPTU) para o caso concreto;

O MM. Julgador *a quo* justificou sua *ratio decendi* com base no Tema 226 STF da Repercuss o Geral (RE 602.347/MG). Naquele caso, se discutiu se as cobran as progressivas de IPTU **antes** da EC 89/2000 se manteriam v lidas uma vez que o STF reconheceu que a dita progressividade s  poderia existir ap s a EC 89, mas - ainda assim, reconheceu parcialmente o direito Municipal para manter v lida a cobran a de IPTU **de acordo com a al quota m nima** naquele caso - mesmo com o reconhecimento da inconstitucionalidade. O racional do Juiz *a quo*   o de justificar

que o Tema 226 teria autorizado exação tributária de período anterior à EC, mantendo-se “incólume” a lei infraconstitucional a despeito da nova redação Magna. Essa leitura é um silogismo enviesado e errado.

O caso é diametralmente oposto ao assunto ITCMD e EC 132; e a bem da verdade, o Tema 226 só soma ao argumento ora esposado. Há uma **GIGANTESCA diferença entre** os dois casos que se pode resumir na escolha do predicado verbo-nominal: **poderá vs. será.**

A EC 89 de 2000 inovou o art. 156 (IPTU) da seguinte maneira:

Art. 3º O § 1º do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

“§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I **poderá”** (NR)

“I – **ser progressivo** em razão do valor do imóvel; e” (AC)*

“II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.” (AC)

Ao escolher a faculdade inerente ao predicado “**poderá**”, permitiu que os Municípios tivessem ou não uma progressividade de suas alíquotas a partir da promulgação da EC 89. Sendo uma faculdade adotar uma graduação (da alíquota mínima à máxima), entendeu o STF as cobranças progressivas de IPTU antes da edição da EC estariam ilegais e que, portanto, deveria ser fixa de acordo com a mínima alíquota vigente à época do fato gerador. O Constituinte Derivado deu uma opção à somar o campo de cobrança tributária, uma faculdade, mas não alterou a ordem tributária. Não havia clara incompatibilidade a revogar por completo a cobrança do fato gerador antes da EC 89.

Já a EC 132/2023 não deu uma opção ao legislador Estadual, pelo contrário, foi imperativo ao dizer que “**será** progressivo”, sendo um comando que não permite uma cobrança “com base na alíquota mínima ou atualmente vigente”. Não é uma faculdade, é uma obrigação. A mudança da legalidade tributária é severa e implica um reajuste de todo sistema Fiscal no que pertine ao ITCMD. Há, portanto, uma incompatibilidade material que não se evidenciou no Tema 226.

No mesmo sentido, a peça inicial do Mandado de Segurança expõe, a fundo, o estudo gramatical, teleológico, principiológico e sistêmico do porquê da **obrigatoriedade** da cobrança progressiva e da consequente ilegalidade irrestrita e imediata da manutenção da alíquota fixa.

Novamente, o objetivo desse recurso é o de retomar o senso de plausibilidade e não discutir o mérito na sua inteireza, de modo a sugerir que, acaso entenda necessário, possa este D. Relator analisar a fundo o tema na exordial no tópico “**Ratio legis: A alíquota é de fato obrigatoriamente progressiva?**”

Diga-se, ainda, que de acordo com a Resolução n. 9 de 1992 do Senado, **não existe alíquota mínima de ITCMD**, tampouco se pode afirmar que a alíquota fixa é igualmente a mínima.

Dito de outra forma, não está correta a afirmação de piso de que existem precedentes das Cortes Superiores que permitem a cobrança de tributos mesmo reconhecendo a sua inconstitucionalidade. Pelo contrário, juntou-se acima no tópico (1) **inúmeros julgados que reafirmam que a revogação tácita ou por assimilação é imediata e não depende**, salvo raros casos (14%) de detalhamento sobre incompatibilidade material ou não (*que também é presente nesse caso*).

Reitera-se a gritante plausibilidade a permitir a análise da liminar de suspensão de exigibilidade.

3. Inadequação do comparativo com a progressividade do Imposto de Renda, só implementado 28 anos depois da CF

O h. Decisor recorrido defende a ausência de plausibilidade do direito recursal também ao argumento de que “*desde 1988, a Constituição prevê a progressividade do Imposto de Renda (IR), mas esta só foi instituída para a tributação do ganho de capital pela Lei no 13.259, de 2016, e nem por isso a cobrança da alíquota fixa nesses casos foi considerada inconstitucional durante o período de 28 anos entre as normas.*”

A conclusão indireta é de que o magistrado entende que a obrigação de progressividade pode ser adotada ao bel prazer dos Estados quando o quiser, até mesmo depois de 28 anos de promulgada a Constituição Federal ou mudanças via EC.

Até poderia se admitir um argumento de prazo de ajuste vs. caducidade de 6-8-12 meses, uma vez que o Estado precisaria de passar uma nova lei frente a mudança Constitucional. Mas nem é esse o argumento do Juiz, que parece entender que o Estado não precisa se ajustar à CF.

E a referência ao Imposto de Renda nos parece, com o devido perdão, equivocada do ponto de vista constitucional por duas razões expostas no Art. 153 e 145 da CF.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

III - renda e proventos de qualquer natureza;

§ 2º O imposto previsto no inciso III:

I - **será informado pelos critérios** da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei;

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

§ 1º **Sempre que possível**, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Por mais que os preceitos de progressividade já estivessem na CF desde 1988, o fato é que - àquela época - não existia a obrigatoriedade da graduação tributária. “Ser informado pelos critérios [...] na forma da lei” **não impõe dever de progressividade**, fato corroborado pelo art. 145 que trazia “sempre que possível” como normativo inicial.

Reitera-se, portanto, que os elementos de convencimento magistral não se sustentam, reforçando-se a plausibilidade do *mandamus* e a necessidade de apreciação (e deferimento) de seu pedido liminar.

4. Ativismo Judicial: decisão de março de 2025 reconhecendo que o ITCMD não é tributo que - uma vez não cobrado - gera grave crise arrecadatória;

A decisão recorrida reforça em algumas passagens a razão de negativa por uma preocupação arrecadatória:

Se assim fosse, os Estados que ainda não aprovaram leis para estabelecer o ITCMD progressivo, quais sejam, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Bahia e Piauí [...] **teriam grave crise arrecadatória**, o que, convenhamos, não foi o objetivo do Constituinte Derivado.

Por outro lado, além de gerar um precedente com efeito multiplicador perigoso que se aplicaria a praticamente qualquer hipótese cessão gratuita (doação), a concessão da liminar impediria o Estado

de cobrar tributo vigente e regularmente exigível, **gerando um grave impacto arrecadatário e administrativo.**

Apesar de importante o racional dos julgadores em relação ao impacto fiscal das decisões judiciais, é igualmente relevante ter em mente em quais situações esse ativismo e consequencialismo judicial pode sobrepor o direito posto e jurisprudencial. Afinal, convenhamos, se o Constituinte Derivado quisesse facultar a progressividade, não teria escolhido o predicado "será", mas apenas repetido a norma da Resolução n. 9 do Senado com o "poderá ser progressivo".

No tema de análise judiciosa do ponto de vista fiscal ou arrecadatário, podemos rebater com duas percepções extremamente válidas:

- A arrecadação do ITCMD no ES não passa de, em média, 0,6% (*zero vírgula seis por cento*) da arrecadação total do estado⁶
- STF entendeu em Março de 2025 que o ITCMD não tem peso arrecadatário ou social suficiente para ativar o pensamento de consequencialismo judicial para modulação de efeitos (grave impacto social ou insegurança jurídica)

A arrecadação de ITCMD é mínima se comparado à receita total dos Estados. No Brasil, a média do ITCMD corresponde a 0,48% da arrecadação total, ao passo que no Espírito Santo fica em torno de 0,6% - na média dos últimos 10 anos.

Até que ponto 0,6% de arrecadação suprime o direito posto e regulado pela Constituição Federal? Até que ponto 0,6% de receita autoriza que milhares de decisões do STF sobre revogação tácita de lei frente EC sejam completamente ignoradas? Até que ponto 0,6% de arrecadação tem o poder de inverter a lógica de proteção constitucional e balanço entre Fisco e Contribuintes de modo a autorizar - na visão do magistrado - que mesmo depois de 28 anos o Estado não se adeque à **obrigatoriedade** constitucional?

A bem da verdade, fosse 0,6% ou 90% de arrecadação, entendemos que o consequencialismo judicial é uma extrapolação do direito judicante - apesar de também reconhecermos a importância

do pensamento. A força impositiva está com o Estado, ficando o jurisdicionado à mercê da inexistência de respeito ao princípio da legalidade. Espera-se do Judiciário o rebalanceamento.

- O Erro do Consequencialismo Judicial e o Recente Entendimento do STF (março de 2025) no sentido de entender que o ITCMD não tem o condão de gerar crise arrecadatória

É dizer, o olhar da decisão judicial tem que ser estritamente jurídico, sem voluntarismo público. Esse *writ* trata de tema de estrito direito Constitucional, e sua análise deve assim se manter.

Esse capítulo vai abordar o tema do consequencialismo judicial, passando pela **proibição** do Juiz de piso modular efeitos, estando adstrito a reconhecer ou não a não-recepção e revogação da lei, sem elastecer conceitos judicantes a favor do Fisco em razão da consequência econômica.

Dois são os temas cruciais desse tópico, um **deles um julgamento do Supremo Tribunal Federal de 28 de Fevereiro de 2025 que NEGOU a modulação de efeitos em relação ao mesmo ITCMD** no Estado do Rio de Janeiro, por não entender ser hipótese suficiente da rara modulação dos efeitos. Outro ponto elementar será uma tese de doutorado cuja banca teve ninguém mais nem menos do que o Ministro Luís Roberto Barroso e os Professores Daniel Sarmento, Ricardo Lobo Torres, Misabel Abreu Machado Derzi e Celso de Albuquerque Silva.

Começemos com a nota de que apenas os Ministros do Supremo Tribunal Federal podem decidir sobre modulação de efeitos com base em elementos financeiros, não sendo prerrogativa esticada à jurisdição difusa dos magistrados de piso afastar preceito de lei em prol da arrecadação dos Estados.

Aos Juízes e Desembargadores cabe, portanto, o reconhecimento da não recepção e da revogação (tácita ou por assimilação) a partir da data de incompatibilidade, evitando, no caso concreto, que o ato coator se opere. O reconhecimento primário, portanto, é a **inexistência** de tributo constituído do ITCMD no ES, sendo vedada a sua exigência (art. 150, CF).

O ITCMD tem sido bastante discutido recentemente. O Tema 1.214 do STF (*leading case n. RE 1363013*) é o mais novo julgado da Suprema Corte sobre o assunto, cuja modulação de efeitos foi decidida dia 28 de Fevereiro de 2025. **Este caso está umbilicalmente ligado ao tema agora em questão.**

Naquele *leading case* (Tema 1214), o Estado do Rio de Janeiro pleiteava a constitucionalidade da cobrança de ITCMD sobre os planos de previdência privada VGBL e PGDL, ao contrário do que havia entendido a corte de piso, que decidiu que esses planos são *um direito do beneficiário por sobrevivência, e não um direito hereditário - tema alheio à nossa discussão*.

Em Dezembro de 2024, os ministros entenderam que não há incidência de ITCMD sobre esses planos de previdência privada, mudando uma prática de décadas de todos os Estados da Federação, que sempre cobraram os respectivos ITCMDs sobre essas montas.

Uma vez reconhecida a extirpação da legislação local do Rio de Janeiro (*naquele caso, pela inconstitucionalidade, e não pela não recepção - que a bem da verdade tem o mesmo efeito prático*) abriu-se a possibilidade de que qualquer contribuinte que tenha pago ITCMD nos últimos 05 anos sobre o PGDL e VGBL possa, a partir de agora, pedir a restituição. **O efeito econômico é estimado em 4,5 bilhões de reais a serem restituídos a título de ITCMD pago de maneira indevida sobre PGDL/GVBL.**

E o Estado do RJ sabe disso, como também se preocupa com a perda de receita futura. Assim, estampou sua preocupação nos Embargos de Declaração de Janeiro de 2025 em que pediu a modulação dos efeitos, para que fosse aplicado o efeito *ex nunc*, produzindo efeitos apenas a partir da decisão de inconstitucionalidade, sem retroagir.

O Ministro Dias Toffoli assim resumiu o pleito Estatal:

Ressaltam que o **Estado do Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal** e que, nesse contexto, **a restituição de valores cobrados a título da tributação em comento pode tornar inviável o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação e comprometer a prestação de serviços públicos e/ou o custeio do funcionalismo estadual.**

Entendem os embargantes que essa situação “tende a se repetir em relação aos demais Estados da Federação”. Nessa toada, apontam perdas em razão da paralisação da cobrança do tributo e a “perspectiva de devolução de vultosos recursos, com o ajuizamento maciço de ações judiciais buscando a restituição dos valores já recolhidos”. Consigam que as ações de restituição do indébito assoberbarão os tribunais de justiça e desaguarão nos tribunais superiores.

O Estado do Rio de Janeiro apontou que:

1. Por estar em regime (*crítico*) de recuperação judicial, poderá vir a ficar comprometido na prestação de serviços públicos e/ou o custeio do funcionalismo estadual;
2. Essa situação tende a se repetir em outros estados;
3. Ocorrerá paralização da cobrança e devolução de vultosos recursos, o que;
4. Trará o ajuizamento maciço de ações judiciais, o que assoberbado os tribunais.

Seria esse um cenário econômico de perda de receitas um motivo justo com forças a modular os efeitos de uma inconstitucionalidade em razão de efeito na arrecadação? Na visão dos Ministros, não, pois motivos econômicos e arrecadatórios (ou perda de receita) não é motivo suficiente para tanto; independentemente da situação das finanças do Estado.

Os Ministros, à unanimidade no dia 28 de Fevereiro de 2025, seguiram o voto do Relator Dias Toffoli, que assim se manifestou:

Afora isso, é importante ter em mente, como aduzi em outra oportunidade (RE nº 595.838/SP-ED, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/15), **que modular os efeitos, no caso dos autos, importaria em negar o próprio direito ao contribuinte** de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.

A segurança jurídica está, na verdade, na proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal, exercendo, assim, o STF o papel que lhe é reservado: o de preservar a Carta da República e os princípios que a ela são insitos.

E com isso, rejeitou os Embargos de Declaração do Estado do Rio de Janeiro pela modulação dos efeitos. No mesmo sentido, os Ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gláudio Dino, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Luiz Fux, André Mendonça, Gilmar Mendes e Luis Roberto Barroso.

Essa mesma decisão do Dias Toffoli traz menções a outros julgados pacificados sobre o tema da modulação dos efeitos no STF, com destaque a três deles:

Ministro Cezar Peluso, RE nº 363.852/MG, “se[,] em todos os casos de decisão de inconstitucionalidade em matéria tributária, o Tribunal dispuser que só valerá dali para a frente, a repetição de indébito tributário e a prescrição não serv[irão] para mais nada”.

Ministra Cármen Lúcia, RE nº 363.852/MG, “a não ser em situações excepcionalíssimas, em que a execução do que nós decidimos gere [m]ais problemas sociais, principalmente, não econômicos ou financeiros, mas sociais, que realmente poderiam ensejar uma prática dessa natureza em caráter excepcionalíssimo, nós temos de manter até o que é pedagógico para os órgãos do Estado. **Não se pode afrontar a Constituição, nem nós aqui, que nos submetemos à Constituição, nem o Congresso Nacional, nem o Poder Executivo. [Errando], eu pago na minha vida pessoal e o Estado paga também quando ele erra. Então, não se pode fazer realmente disso uma prática comum**”.

Ministro Joaquim Barbosa, AI nº 557.237/RJ, “em matéria tributária, a aplicação de efeitos prospectivos à declaração incidental de inconstitucionalidade **demanda um grau ainda mais elevado de parcimônia**, porquanto é um truísmo afirmar que os valores arrecadados com a tributação se destinam ao emprego em finalidades públicas. Portanto, **não basta ao sujeito ativo apontar a destinação de índole pública do produto arrecadado para justificar a modulação temporal dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade**, sob o risco de se inviabilizar qualquer pretensão de restituição de indébito tributário, em evidente prejuízo da guarda da constitucionalidade e da legalidade das normas que instituem as exações. **Evidentemente, a possibilidade que o sistema jurídico confere ao Supremo Tribunal Federal para modular no tempo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e a destinação do produto da arrecadação ao exercício de atividades estatais não podem redundar na imunização do Estado ao dever de zelar pela validade das normas jurídicas que cria, favorecendo assim a especulação legal**”.

O aposentado Ministro Joaquim Barbosa foi preciso em dizer o que ora se repete em destaque: **“possibilidade que o sistema jurídico confere ao Supremo Tribunal Federal para modular no tempo [...] não podem redundar na imunização do Estado ao dever de zelar pela validade das normas jurídicas que cria, favorecendo assim a especulação legal”**.

A Ministra Cármen Lúcia ponderou, como acima visto, que a excepcionalidade que permite ao STF a modular efeitos vem de problemas sociais, e não econômicos ou financeiros, mas sociais - ela repetiu.

Mesmo o Estado do RJ estando em recuperação judicial e com altos problemas econômicos e financeiros, o Supremo não transportou esse argumento para a seara social, tampouco encontrou função social no ITCMD (*que nem se discute ser arrecadatória, e não social*).

Tais fatos não são suficientes para modular os efeitos - sob pena de ser uma imunização do Estado ao **dever de zelar pela validade das normas**, o que se aplica ao caso presente em não ter uma visão consequencialista arrecadatória como pressuposto de julgamento dos Magistrados.

E aqui entramos numa questão interessante: o dever de zelar pela validade das normas. A EC 132/2023 foi promulgada em 21 de Dezembro de 2023, ou seja, há 18 meses atrás - e até o momento o Estado do Espírito Santo não se movimentou para zelar a validade da norma.

O Estado erra, por mais que tenha uma excelente Procuradoria Jurídica que assessora a SEFAZ e seu núcleo legislativo. O erro do Estado do Espírito Santo não pode ser maior do que o respeito à Constituição Federal, de modo que não cabe falar - sequer - em um eventual período de cumprimento não respeitado (*ou caducidade*). Esticando - muito - a corda da interpretação jurídica, poder-se-ia extrapolar dizendo que o período de Reserva de Anterioridade Geral e Nonagesimal seria um período de ajuste dos Estados, o que também já teria caducado.

Aliás, podemos argumentar que passados 18 meses da vigência da EC 132, caduco estaria qualquer eventual período de ajuste - o que, no entanto, não foi concedido pela Lei Maior. A vontade do Legislador Constituinte Derivado foi de extirpar, **de imediato**, a lei estadual ora em questão do ordenamento jurídico.

E a vontade do Legislador Constitucional deve ser sempre mantida, como também nos casos de modulação dos efeitos ou afastamento do ativismo judicial em prol da receita estatal.

5. Concessão da Tutela de Urgência: *fumus bonis iuris*, *periculum in mora*, reversibilidade da medida, ausência de prejuízo na concessão e direito potestativo do contribuinte (no pedido subsidiário)

Os tópicos até então esposados tiveram o cunho precípuo de resgatar a **plausibilidade e relevância da matéria de piso** para que em cognição ainda sumária o pedido liminar fosse analisado e deferido. Por mais que esse causídico tenha tido a preocupação de deixar os temas centrais de direito para o processo de origem, é fato que a análise liminar deve igualmente passar pelo direito, notadamente nas suas iniciais percepções da fumaça do bom direito (*revogação tácita por não recepção*). O Juiz de piso descartou, por completo, o *fumus bonis iuris*, ainda que usando raciocínio jurídico destoante dos próprios julgados que trouxe e da vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Haja visto argumento anterior, o assunto de revogação tácita por posterior EC não é novo, mas esse causídico inova ao trazer essa discussão para o ITCMD no Espírito Santo. Assim, por mais que seja um tema ainda não profundamente enfrentado pelo Judiciário local, não se pode retirar a sua plausibilidade ou lógica jurídica. O *fumus bonis iuris* é claramente presente, bastando a comparação com as centenas de decisões sobre revogação acima colacionadas.

Meritoriamente, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, quais sejam, o ***fumus boni iuris*** e o ***periculum in mora***, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

O ***fumus boni iuris*** está plenamente caracterizado pela aludida (*e em cognição preliminar, possível*) revogação tácita que cria uma ausência de base legal válida para a exigência do ITCMD no Estado do Espírito Santo, uma vez que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, em 21 de dezembro de 2023, foram automaticamente revogados os artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.011/2013, os quais disciplinavam a hipótese de incidência do tributo.

No curso do processo será discutido entre as partes e decidido pelo Juiz se há incompatibilidade material e/ou se há algum tipo de modulação do ordenamento jurídico em prol de uma interpretação flexível da legislação tributária. Mas o *fumus* está inegavelmente presente.

Nos termos do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, **é vedada a exigência de tributo sem previsão legal específica**, o que significa que nenhum ITCMD pode ser cobrado pelo Estado do Espírito Santo até que nova legislação seja editada em conformidade com a nova sistemática constitucional. É como entende o STF:

É inconstitucional a exigência de tributo sem a devida previsão legal, sendo vedada a criação de obrigação tributária por ato infralegal” (STF, ADI 5.135/DF, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJ 26/09/2019).

O ***periculum in mora*** decorre do iminente risco de o Impetrante ser ilegalmente compelido a recolher ITCMD com base em uma legislação inexistente, sob pena de:

- Recebimento de guia de pagamento indevida, baseada em normas revogadas e inconstitucionais;
- Abertura de processo administrativo tributário, sujeitando eventual cobrança coercitiva pelo Estado;
- Possível inscrição em dívida ativa e execução fiscal indevida, caso não haja pagamento do tributo que sequer possui fundamento legal vigente.

O STJ é uníssono em aceitar o Mandado de Segurança Preventivo na esfera tributária, aduzindo, ainda, **que o writ é cabível para evitar que a autoridade coatora proceda ao lançamento fiscal ilegal**, uma vez que, à luz do art. 142, CTN, o lançamento tributário é atividade administrativa vinculada e obrigatória:

Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

STJ: EDcl no AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.169.402 - SP (2017/0230136-2)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS SOBRE ATIVIDADES EXERCIDAS POR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. ACÓRDÃO EMBARGADO FIRMADO COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO PARA AFASTAR O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DO WRIT OF MANDAMUS NA MODALIDADE PREVENTIVA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS REGULARMENTE INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE PROVER O RECURSO ESPECIAL, PARA, RECONHECENDO O CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIÇÃO DAS QUESTÕES REMANESCENTES.

Outros Precedentes no STJ: AgInt no REsp. 1.270.600/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.6.2018; AgRg no AREsp. 543.226/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.12.2015; AgRg no Ag 1.302.289/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 8.11.2010; REsp. 860.538/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.10.2008.

No caso dos autos, o *writ* se justifica na medida em que os Contribuintes objetivam evitar que atos abusivos de cobrança venham ocorrer, haja vista que o Estado do ES não suspendeu as cobranças de ITCMD desde a revogação da lei estadual pela não recepção e, pelo contrário, o estado acredita estar obrigado - por força do art. 142, CTN, a proceder com as cobranças de 4% sobre o valor da doação para fins de ITCMD.

A exigência ilegal do ITCMD, se não impedida de imediato, levaria o Impetrante a um ônus desnecessário e ilegal, obrigando-o a quitar um tributo inexistente para, posteriormente, ingressar com ação regressiva, submetendo-se a um longo e custoso processo judicial.

O Superior Tribunal de Justiça também reconheceu a possibilidade de concessão de liminar em mandado de segurança preventivo para impedir exigências tributárias sem base legal válida, evitando que o contribuinte seja indevidamente prejudicado:

"É cabível a concessão de liminar em mandado de segurança para afastar a exigência de tributo, quando inexistente base legal para sua cobrança, evitando-se a submissão do contribuinte a cobrança indevida e necessidade de repetição de indébito." (STJ, AgInt no RMS 66.108/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 16/12/2022).

Dessa forma, impedir o Estado do Espírito Santo de exigir ITCMD sem norma válida é medida de rigor, sob pena de afronta direta à legalidade tributária e segurança jurídica.

Ademais, o artigo 151, IV, do CTN prevê que a (*pretensa*) exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por concessão de medida liminar em mandado de segurança, hipótese que se aplica perfeitamente ao presente caso, pois há evidente ausência de base legal válida para a cobrança do ITCMD.

- **Do Inequívoco Direito do Contribuinte ao Depósito Judicial**

O pedido principal do Mandado de Segurança e desse Agravo de Instrumento é o de que o Estado se abstenha de cobrar ITCMD contra os Impetrantes em razão da ausência de legalidade da cobrança até que o mérito seja julgado.

Acaso o *fumus bonis iuris* não seja identificado em matéria de cognição sumária por este Relator, há de se considerar que o depósito judicial contido no art. 151, II do CTH é um **direito inequívoco dos contribuintes**, sendo até mesmo desnecessária uma decisão judicial autorizatória.

O MS foi protocolado dia 14 de Julho, e logo no dia seguinte o MM. Magistrado já proferiu a decisão ora recorrida. Os impetrantes sequer tiveram tempo de proceder ao depósito judicial por liberalidade própria.

Vale a ressalva, no entanto, de que o STJ entende que o depósito judicial é um **direito do contribuinte**, e pode ser feito à despeito de autorização judicial:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MITIGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735/STF. ART. 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DO CONTRIBUINTE. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS AO TESOURO ESTADUAL PARA IMEDIATA UTILIZAÇÃO. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 151/2015. INOCORRÊNCIA DE ABALO ÀS CONTAS PÚBLICAS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II A jurisprudência desta Corte mitiga a incidência da Súmula n. 735/STF em contexto no qual prescindível incursão sobre o mérito da causa, discutindo-se, tão somente, os requisitos previstos em lei para a concessão de provimento cautelar, a exemplo das condições legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito de seu montante integral. Precedentes. III – **O depósito do valor total do crédito tributário controvertido, a fim de suspender sua exigibilidade, constitui direito subjetivo do contribuinte e cujo exercício prescinde de autorização judicial e de quaisquer outros requisitos a par de sua integralidade. Inteligência do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Precedentes.** IV – De acordo com o art. 3º da Lei Complementar n. 151/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante, viável a transferência de parcela dos valores judicialmente consignados para a conta única do Tesouro Estadual, permitindo-se a imediata utilização dos recursos depositados pelo contribuinte sem risco de severo impacto nas contas públicas, o que, aliás, sequer foi comprovado nestes autos. V – Demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, à vista dos depósitos efetuados pelo contribuinte. VI – Agravo Interno improvido. AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 259 (e-Doc 42941564) | 2024/0165911-9, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: REGINA HELENA COSTA. **Julgado em 19/08/2024**, Publicado em 21/08/2024.

Requer-se, **subsidiariamente**, que seja autorizado o depósito judicial de R\$ 121.207,60 (*cento e vinte e um mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos*) - ou 4% sobre valor cedido conforme patrimônio líquido das empresas, como forma de garantir a suspensão da exigibilidade tributária.

IV – DO PREQUESTIONAMENTO

Para embasar eventual necessidade de se recorrer às superiores instâncias, o agravante requer, neste ato, manifestação expressa e específica desta Colenda Câmara a respeito dos dispositivos que fundamentaram o presente recurso, quais sejam, os arts. 10, 12 e 13 da Lei Estadual 10.011 de 2013 e, sobretudo, da CF art. 24, 146 e 155, cumulado com dispositivos infraconstitucionais tal como o art. 2º da LICC, a Lei 95 de 1998 (art. 9º) e os art. 142, 150 e 151 do CTN.

V – PEDIDO

Diante do exposto, requer o Agravante, que se digne este E. TJES, por seu nobre Relator, a retificar a decisão interlocutória proferida pelo digno magistrado *a quo*, dando provimento ao presente recurso, para que, com fins no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, **conceda a tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de emitir guias e/ou cobrar ITCMD em relação às Declarações n. 20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989, diante do *fumus bonis iuris*, *periculum in mora* e a ausência de prejuízo ao Estado**, medida que deve ser confirmada no provimento final deste Recurso;

Subsidiariamente, requer-se o deferimento de depósito judicial no valor de R\$ 121.207,60 (*cento e vinte e um mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos*) - ou 4% sobre valor cedido conforme patrimônio líquido das empresas, como forma de garantir a suspensão da exigibilidade tributária;

Requer-se ainda a intimação do Estado do Espírito Santo, pela sua Procuradoria localizada na Av. Nossa Sra. da Penha, 1590 - Barro Vermelho, Vitória - ES, 29057-550, sem qualquer procurador até o momento vinculado à demanda de piso, para apresentar contrarrazões. Requer-se ainda, se cabível, a intimação do Ministério Público para acompanhar o feito por eventual interesse público.

A Agravante se compromete a informar o Juízo de Origem em 03 dias. Atendendo ao comando do artigo 1016, inciso I do CPC, a Agravante informa o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo a saber:

PELO AGRAVANTE: Dr. Lucas Pimenta Judice, brasileiro, casado, portador da OAB/ES 14.477 e com endereço profissional à Rua João da Cruz, n. 25, SI 401, Praia do Canto, Vitória/ES e endereço eletrônico lucasjudice@gmail.com ou pi@pimentajudice.com.br

PELO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO localizada na Av. Nossa Sra. da Penha, 1590 - Barro Vermelho, Vitória - ES, 29057-550, sem qualquer procurador até o momento vinculado à demanda de piso.

Por derradeiro, em atenção ao preconizado no artigo 105, § 3º e artigo 272, §§ 1º e 2º ambos do CPC, postula para que todas as intimações de despachos judiciais e demais decisões sejam feitas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do **Dr. Lucas Pimenta Judice, OAB/ES 14.477**, sob pena de nulidade aos atos que vierem a ser intimados e os posteriormente praticados.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

LUCAS PIMENTA JUDICE
OAB/ES 14.477

VI – INDICAÇÃO E JUNTADA DE PEÇAS

Embora não seja exigida a juntada das peças ao agravo, nos termos do artigo 1.017, §5º, do CPC, apresenta-se, para fins de regularidade formal e melhor compreensão do recurso, a indicação das peças essenciais e os seus IDs nos autos, tudo com a devida declaração de autenticidade:

- **Doc 1** - Cópia integral dos autos de origem
 - No qual se encontra a
 - Peça exordial: ID 72987271
 - Procuração do Advogado da Agravante: ID 72987272
 - Declarações SEFAZ que se busca suspensão: ID 72987273
 - Decisão Agravada: 73073282
 - Certidão de Intimação da Decisão Agravada: Intimação Diário n. 12882583, 12882584, 12882585 e 12882586, disponibilizado dia 16 de Julho de 2025.
 - **Obs:** Ainda não houve Contestação ou informações do ente coator
- **Doc 2** - Lei 10.011 de 2013 do Estado do Espírito Santo: com destaque aos artigos 10, 12 e 13, revogados tacitamente pela EC 132/2023
- **Doc 3** - Guia de Preparo desse Agravo de Instrumento
- **Doc 4** - Pagamento das Custas Recursais
- **Doc 5 - Fontes:** estudo organizado de 120 decisões recentes do STF sobre o tema de revogação tácita frente à emenda constitucional superveniente que torna a lei antecedente imediatamente extirpada pela não-recepção.